

1501224-25.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... ser mantida, notadamente, para a garantia da ordem pública. Como se sabe o crime de tráfico é o que sustenta inúmeras facções criminosas que com o dinheiro arrecado pela venda de drogas adquirem armamento de alto calibre e praticam diversos outros delitos colocando em risco toda a sociedade.

Por fim, em razão do disposto no art. 316 do Código de Processo Penal já com a nova

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1501224-25.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501224-25.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLAN DIONES MARTINS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

ALLAN DIONES MARTINS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art.155, §4º, inciso II, do Código Penal, pois, segundo apurado, no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 20h25min, na Rua Trajano, 10, Lapa, São Paulo/SP, já qualificado, subtraiu, para si, mediante destreza, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular marca Motorola, Moto G5 (avaliado em R\$ 700,00), pertencente à vítima F.Z.S.S.T.O.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado, notificado e apresentou resposta à acusação.

Após a manutenção do recebimento da denúncia, não sendo o caso de suspensão do processo ou de acordo de não persecução penal, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas a vítima, dois policiais e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu, a absolvição do réu, por insuficiência probatória para a condenação, ou ainda em razão da aplicação do princípio da insignificância, e em caso de eventual condenação, buscou, em suma, o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, II do CP, ou a desclassificação da conduta do réu para o delito de receptação, a fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal em face do privilégio, estabelecimento de regime inicial aberto para o cumprimento de

pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É o relatório.

Fundamento e decido.

A absolvição do acusado é totalmente descabida, já que os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade deleitava veio configurada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão/entrega do aparelho celular, tudo aliado a firme e segura prova oral colhida em audiência, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é inconteste.

Os dois policiais ouvidos em juízo afirmaram que caminhavam pela região do mercado da Lapa ocasião em que o réu passou por eles com um celular na cintura o que fez com que ele fosse abordado.

Durante revista pessoal, ao ser indagado sobre a procedência do aparelho celular no início disse que o adquiriu em um rolo.

Ocorre que durante o procedimento o telefone tocou e foi atendido pelos policiais, ocasião em que uma mulher se identificou como sendo filha da proprietária do objeto. Os policiais então indagaram desta pessoa onde sua mãe poderia ser encontrada e com após a indicação do local, outra equipe policial foi acionada e conseguiu localizar a vítima.

Novamente o réu foi indagado sobre o aparelho celular e ainda se era pai de uma mulher, ocasião em que mudou sua versão alegando que encontrou o celular no chão e o pegou. Diante dessas versões conflitantes o réu foi preso e conduzido ao Distrito Policial.

Já no distrito, a vítima foi ouvida ocasião em que reconheceu seu aparelho celular, bem como disse que o réu caminhava na via pública onde também estava e em um dado momento, percebeu que o réu a seguia e logo em seguida, sentiu um esbarrão.

Disse, ainda, que não percebeu a subtração e que continuou caminhando e ao chegar próximo a um mercado onde iria fazer algumas compras e colocar as mãos na bolsa não encontrou seu aparelho celular que ali estava. Logo em seguida foi abordada por um policial que afirmou que seu celular havia sido encontrado com um rapaz nas proximidades do mercado da Lapa e diante disso foi levada à Delegacia onde reconheceu o réu como sendo a pessoa que a seguiu na via pública e também o aparelho celular que foi apreendido com o réu e que lhe foi prontamente restituído. O réu ao ser interrogado em juízo negou o furto. Disse que vendia balas nas proximidades da Igreja Bola de Neve, que fica na Lapa, em um local bem movimentado e encontrou um aparelho celular no chão com a bateria ao lado e por isso o pegou. Em seguida foi abordado pelos policiais e foi preso. Afirmou, ainda que havia outras pessoas no local que poderiam confirmar sua versão, mas não tem condições de qualificá-las.

Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas outra solução não há que a condenação do acusado.

Não há que se falar em falta de provas quanto a autoria do delito.

De fato, embora a vítima não tenha tido condições de afirmar categoricamente que foi o réu quem nela esbarrrou, ela foi firme em apontar o acusado como sendo a pessoa que passou a segui-la enquanto caminhava pela via pública.

Tais declarações, aliadas, ainda ao fato de que o réu foi encontrado na posse do aparelho subtraído, sem conseguir dar uma versão segura sobre a procedência do bem, nem mesmo apresentar ou qualificar eventuais pessoas que pudessem comprovar sua versão, já são suficientes para comprovar que o crime em tela foi praticado pelo acusado.

Não se podendo deixar de considerar que tal espécie de delito é, em regra, dependente de clandestinidade.

Não se pratica furto às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas. Por isso mesmo, a prova suficiente à condenação não é daquelas contundentes, vistosos, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento.

Veja-se ademais que a palavra da vítima deve merecer crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecida pessoa, não teria ela proveito algum em mentir e

até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar o verdadeiro culpado.

Aliás, esse entendimento é reiterado na jurisprudência: JTACrimSP, 86/226, 91/407, 94/341 e 100/250-266; JTJ-SP, 154/306, 165/339, 176/324 e 184/305; JTAERGS, 85/97.

Lembra-se, aqui, trecho da lição do clássico NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA, que espanca qualquer dúvida a respeito de eventual suspeita da palavra do ofendido: "A animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido, nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, porque tu, como ofendido, tem ódio contra ele -, é uma verdadeira e flagrante contradição; é reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, pois, a aversão contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, mesmo de terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui" (cf. tradução brasileira, págs. 409-10).

Além disso, o celular da vítima foi encontrado na posse do réu, fato este por ele mesmo confirmado e na esteira da doutrina e da jurisprudência, "em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuta a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (TACrimSP, 10ª Câ., Ap. 250.141, rel. Juiz PENTEADO DE MORAES, in JTACrimSP, 66/410). Trazendo à colação o mesmo aresto existem outros acórdãos (cf. TACrimSP, 11ª Câ., Ap. 569.32308, rel. Juiz SIDNEI BENETI, in RT, 656/303; TACrimSP, 4º Grupo, Rev. 279.894-3, rel. Juiz LUIZ AMBRA, in RT, 728/543; STJ, 5ª Turma, Resp. 77.868/SP, rel. Min. FÉLIX FISCHER, in RT, 741/594).

Há que se asseverar, ainda, apenas a título de fundamentação e não como forma "apologética e ideológica de defesa aos agentes de segurança pública", como sugeriu a nobre Defesa que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas. Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos, apesar das alegações da Defesa, que tentou comprovar sua posição esta sim tendenciosa e apologética e ideológica com dados não comprovados e que em nada se assemelham ao caso em concreto que deve ser o mote para o julgamento.

Confira-se: Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Também que não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância e tão-somente em razão do valor que ela atribuiu a seu aparelho celular já que comprado, de "segunda mão" de um parente seu.

Isso porque se trata de uma construção jurisprudencial que deve ser aceita com ressalvas, sob pena de se cancelar judicialmente a impunidade que assola nosso país. Como bem definiu o Ministro Celso de Mello, em acórdão paradigma sobre a matéria (HC 84.412-0/SP), o princípio da insignificância só deve ser reconhecido quando presentes simultaneamente quatro vetores: 1) a mínima ofensividade da conduta do agente, 2) a nenhuma periculosidade social da ação, 3) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e 4) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso vertente, a lesão se revelou significativa não apenas em razão do valor do bem subtraídos, sendo sua conduta é típica e se revestiu de relevância para a seara penal.

Não é diverso o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRIVILÉGIO. ART. 155, §§ 2º E 4º, CP. CONCESSÃO DE OFÍCIO DO HC. 1. A questão de direito tratada neste writ, consoante a tese exposta pelo impetrante na petição inicial, é a suposta atipicidade da conduta realizada pelo paciente com base na teoria da insignificância, o que deverá conduzir à absolvição por falta de lesividade ou ofensividade ao bem jurídico tutelado na norma penal. 2. O fato insignificante (ou irrelevante penal) é excluído de tipicidade penal, podendo, por óbvio, ser objeto de tratamento mais adequado em outras áreas do Direito, como ilícito civil ou falta administrativa. 3. Não considero apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância. Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desaparecia do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º). 4. A lesão se revelou significativa não apenas em razão do valor do bem subtraído, mas principalmente em virtude do concurso de três pessoas para a prática do crime (o paciente e dois adolescentes). De acordo com a conclusão objetiva do caso concreto, não foi mínima a ofensividade da conduta do agente, sendo reprovável o comportamento do paciente. 5. Compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4º) e o privilégio (CP, art. 155, § 2º), desde que não haja imposição apenas da pena de multa ao paciente. 6. Habeas corpus denegado. Concessão da ordem de ofício por outro fundamento (HC 94765, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 09/09/2008, DJe-182 DIVULG 25-09-2008 PUBLIC 26-09-2008 EMENT VOL-02334-03 PP-00575).

No caso em tela, ainda que a vítima tenha dito que adquiriu o bem já usado pelo valor de R\$200,00 de um parente seu, há muito tempo, ela também foi firme em declarar precisa do aparelho celular para trabalhar e que não sabia atribuir o atual valor ao bem, já que não tinha qualquer intenção em troca-lo.

Assim sendo, ainda que considerarmos o valor por ela atribuído ao bem, e não o declarado no auto de avaliação de fls. 13, fixado em R\$ 700,00, tal fato, por si só não afasta a reprovabilidade da conduta do acusado.

Isso porque, não se pode olvidar que se sua ação for taxada judicialmente como insignificante isso com certeza irá criar na mente do acusado a falsa permissão para continuar a subtrair coisas que não lhe pertencem, o que deve ser sempre combatido e não estimulado pelo poder judiciário, sob pena de gerar ainda mais a sensação de impunidade extrema que assola nosso país.

Ressalta-se ademais, que além de reincidente o réu ostenta diversas outras condenações por crime contra o patrimônio o que demonstra que sua conduta não deve ser considerada de baixa reprovabilidade, no ponto de se levar a uma absolvição. De outra banda, não que se falar em afastamento da destreza, que se caracteriza pela habilidade física ou manual do agente que possibilita a subtração sem que a vítima dela se aperceba.

No caso em apreço, a vítima, disse que o réu caminhava pela via pública e passou a segui-la e que logo em seguida sentiu um esbarrão e continuou sua caminhada até o supermercado onde percebeu que seu celular já não mais se encontrava dentro de sua bolsa.

Portanto, claro restou que o réu demonstrou possuir habilidade especial para a subtração, pois a vítima sequer percebeu que não estava mais na posse da do celular

que lhe foi subtraído, fato este que foi por ela confirmado na fase policial. Neste sentido: "Caracteriza o delito de furto qualificado pela destreza a conduta do agente que, valendo-se da arte vulgarmente conhecida como 'punga', surrupia dinheiro do bolso do ofendido sem que este o perceba" (RJDTACRIM 32/179). Também não há que desclassificar a conduta do furto para a de receptação simples já que não há nos autos qualquer elemento para tanto, já que o réu disse apenas e tão-somente, que achou o celular no chão e dele se apoderou. Por fim, ainda que a Defesa tenha tentado de todo e qualquer modo desconfigurar a figura do flagrante, afirmando em várias oportunidades durante suas perguntas que o furto teria acontecido há bastante tempo da prisão do réu, isso de fato não ocorreu.

A vítima disse que foi encontrada pelos policiais, enquanto ainda fazia o trajeto de seu trabalho para a casa, aproximadamente uma hora após a subtração e os policiais ainda disseram que o réu foi apreendido na região do mercado da Lapa que fica bem próximo do Shopping da Lapa e do local em que a vítima foi furtada.

Feitas todas estas ponderações, caracterizada, portanto, a infração penal a condenação é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena.

O réu é reincidente, já tendo sido condenada definitivamente nos autos nº 0007668-20.2017.8.26.0198, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Santo Amaro, (fls. 23), o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena. Se não bastasse isso, possui várias outras condenações que serão tidas nesta fase como antecedentes criminais. Assim considerando as outras 02 execuções atestadas a fls. 76/88, decorrentes das condenações proferidas perante a 9ª Vara Criminal Central e 24ª Vara Criminal da Capital, a pena base deve ser aumentada em 1/4, termos do disposto no art. 59 do Código Penal, perfazendo, 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Neste ponto, apenas a título de fundamentação, não há que se falar em descon sideração das condenações acima apontadas apenas e tão somente pelo decurso do tempo já transcorrido, sob pena de se ferir de morte o princípio da individualização da pena.

De fato, se por um lado elas não podem mais serem consideradas como agravantes em razão do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, fato é que nada impede de considerá-las como maus antecedentes, já que demonstram a personalidade criminosa do acusado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

STJ- "condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes" (HC 456891/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.10.2018).

E ainda, conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, "não constitui ilegalidade o fato da sentença considerar os antecedentes criminais e outras circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, aumentando, depois, a pena base, em razão da reincidência" (HC nº 1.990, Rel. Min. Carlos Veloso, DJU de 22.09.95, p. 30.591).

"Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).

Na segunda fase, é o caso de se reconhecer a agravante da reincidência acima apontada e ainda que o crime foi cometido durante a vigência de estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020. Neste ponto, respeitadas posições em contrário, para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal. Desse modo, a pena deve agravada em mais em 1/5 (um quinto), alcançando o patamar de 2 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Neste sentido:

"Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos" (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: "(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

"Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias." (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Autos nº 1509419-67.2020-"O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença", escreveu o magistrado em seu voto. "De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência."

O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais

foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), "a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda" (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

"Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade." (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

No caso em tela, estávamos frente a uma nova variante, a ômicron, que vinha matando milhares de pessoas.

Não há atenuantes a se considerar.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a se considerar.

Também não há que se falar em aplicação do furto privilegiado, notadamente em razão da reincidência do acusado que por si só afasta a aplicação do disposto no §2º, do art. 155, do Código Penal.

Diante do exposto julgo PROCEDENTE, a ação penal que a Justiça Pública move contra o réu para condená-lo à pena de 2 anos, 10 meses e 16 dias, e 14 dias-multa calculados na base do valor unitário mínimo, por estar incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

O dias-multa foram fixados no mínimo legal, já que não há nos autos provas da condição econômica do acusado.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado pois se ajusta e convém a acusado. Trata-se de acusado já condenado por outros crime contra o patrimônio e que sempre ao se ver solto, volta a delinquir, o que demonstra que não está apto a conviver em sociedade.

Cabe ainda aqui invocar enérgica e incontrastável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 65.501-SP, verbis: ``O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias'' (RTJ 123/547).

Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do CP. (cf., exemplificativamente, ac. un. na Ap. nº 673.255/1, de São Paulo).

"Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de

escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP)" (STJ, AgRg no HC 490.175/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/05/2019, DJe 11/06/2019).

Ademais, levando-se em conta a reincidência, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do que dispõe o art. 44, do Código Penal.

Em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Ademais, remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Destarte, não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, já que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, que deve ser mantida, notadamente, para a garantia da ordem pública. Como se sabe o crime de tráfico é o que sustenta inúmeras facções criminosas que com o dinheiro arrecado pela venda de drogas adquirem armamento de alto calibre e praticam diversos outros delitos colocando em risco toda a sociedade.

Por fim, em razão do disposto no art. 316 do Código de Processo Penal já com a nova redação, reviso a decisão que decretou sua prisão preventiva e o faço para manter a segregação cautelar pelos fundamentos acima impostos.

Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso, oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos que ficam desde já homologados salvo se houver impugnação das partes.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

São Paulo, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA